

1509572-03.2020.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Margot Chrysostomo Corrêa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/09/2022

... CORPUS. CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.

APLICAÇÃO DA LEI N. 8.072/90 AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES

PRIVILEGIADO: INVIABILIDADE. HEDIONDEZ NÃO CARACTERIZADA. ORDEM CONCEDIDA. 1. O

tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

6ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1509572-03.2020.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1509572-03.2020.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
(COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2107124/2020 - 25º D.P. PARELHEIROS, 11198691 - 25º D.P. PARELHEIROS, 1333/20/225 - 25º D.P. PARELHEIROS, 2107124 - 25º D.P. PARELHEIROS, 1333/20/225 - 25º D.P.

PARELHEIROS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCEL EDUARDO DE OLIVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Margot Chrysostomo Corrêa

Vistos.

MARCEL EDUARDO DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06. Isso porque, no dia 30 de abril de 2020, por volta das 13h40min, na Rua Alba Valdez, 1, Grajau, nesta Capital, o acusado vendia e trazia consigo para fins de tráfico, 47 (quarenta e sete) porções de cocaína, com o peso total de 32,5 gramas; 06 (seis) pedras de crack, com peso de 1,6 gramas; e 49 (quarenta e nove) porções de maconha, com peso de 72,4 gramas, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Narra a denúncia que policiais civis realizavam diligências no local após receberem a informação de que na localidade era realizado tráfico de entorpecentes. Ao comparecerem ao local os policiais avistaram o acusado e notaram que por diversas vezes ele se aproximava de pessoas que o procuravam e com elas trocava algo, entregando o que retirava de uma pochete, em atitude característica do tráfico de drogas. Diante daquela cena suspeita os policiais optaram por abordar o acusado, encontrando com ele a pochete vista anteriormente, dentro da qual estavam acondicionadas as substâncias entorpecentes já indicadas. Marcel, então, foi conduzido ao distrito policial e, em solo policial, optou por manifestar-se apenas em Juízo.

Oferecida a denúncia de fls. 01/03, aditada às fls. 112, foi ela recebida por despacho no dia 13 de maio de 2020 (fls. 118/119). Consequentemente, o acusado foi citado (fls. 114), vindo aos autos, no prazo legal, a defesa prévia (fls. 73/79). Não sendo supridos os requisitos para a absolvição sumária, agendou-se uma audiência de instrução e julgamento para o dia 10 de março de 2021 e uma audiência de continuação para o dia 12 de setembro de 2022 (fls. 187/188).

Durante a instrução de causa, foram ouvidas duas testemunhas policiais bem como o réu, interrogado ao final.

Encerrada instrução criminal a douta Promotora de Justiça requereu a condenação do acusado nos termos da denúncia. Requereu, quanto a dosimetria da pena, concordou com a aplicação do redutor em seu percentual mínimo diante da quantidade e variedade de pena e regime aberto.

Defesa requer a absolvição do acusado, nos termos do artigo 386, VII ou então a desclassificação para o artigo 28 da mesma lei.

Encontram-se nos autos, ainda, o boletim de ocorrência alusivo aos fatos (fls. 05/07); o auto de prisão em flagrante (fls. 04); o auto de exibição e apreensão (fls. 10); o laudo pericial (fls. 18/21; 196/198); bem como as folhas de antecedentes do acusado (fls. 22/27; 61).

É o relatório.

Fundamento e decido.

É procedente a ação penal porque, ao cabo da instrução criminal restou perfeitamente delineada a autoria e a materialidade do crime tipificado pelo artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06 conforme mais adiante se verá.

Com efeito, a materialidade delitativa está comprovada pelo teor do auto de exibição e apreensão (fls.10) e dos laudos de constatação provisória (fls.18/21), bem como pelo laudo toxicológico definitivo de substância entorpecente (fls. 196/198), com resultados positivos para COCAÍNA e TETRAHIDOCANNABINOL (THC).

A autoria do delito, por seu turno, foi evidenciada pelo conjunto da prova oral colhida no curso da ação penal e pelos demais informes colhidos na fase inquisitiva.

De fato, os elementos informativos constantes no auto de prisão em flagrante bem como a prova oral produzida autorizam o édito condenatório.

Em juízo os policiais que participaram da prisão do acusado foram ouvidos, vejamos. Ademir recordou-se que os fatos ocorreram na semana em que perdeu o pai. Perdeu o pai uma semana antes. Fez varias prisões mas recorda-se do acusado e presenciou quando vários usuários eram servidos por ele, tipo drive thru. Observou os fatos e foi em direção dele a pé. Ele estava com uma pochete e os demais correram. Ele não estava com o dinheiro. Os fatos ocorreram entre 13 ou 14 horas. Nesse dia fez mais um ou dois flagrantes, não se recorda o que ele disse a respeito dos fatos. Não conhecia o réu antes dos fatos.

Adriana também recordou-se que o acusado foi preso há dois anos atrás, por trafico de drogas. Tinham várias denúncias. O local é ponto de trafico, tipo drive thru. Foram até o local e presenciaram o acusado fazendo mercancia. O acusado estava parado. As pessoas paravam e ele entregava as drogas para as pessoas. Ademir foi na frente e a depoente foi atrás. A campana é feita por dois minutos no máximo. Viu o momento em que ele abriu a pochete para pegar a droga. Ademir fez a revista e apreendeu a pochete com a droga. Outras pessoa com a qual ele estava tendo contato

fugiu. Ele vendeu drogas para um garoto que estava a pé e fugiu. A campana estava há uns 15 mestros. Não se recorda de como era a pochete porque prendeu mais gente no dia, estava em uma operação pelo 25º DP. Acredita que estava em 3 ou 4 equipes.

Como se vê, o quadro probatório é sólido e não deixa dúvidas acerca da conduta delituosa do acusado. Os elementos de convicção colhidos na fase policial e em juízo revelam-se firmes e substanciais, apontando-o com segurança como agente criminoso, no caso vertente.

É sabido que no processo penal por tráfico normalmente a prova acusatória consubstancia-se em depoimentos de policiais, civis ou militares, que efetivam a apreensão da droga. E presume-se regular a atuação de agentes públicos investidos no cargo para segurança de todos, pois seria paradoxal que o Estado atribuisse a uma pessoa a execução do ato administrativo de polícia preventiva e repressiva, mas desmerecesse sua palavra.

É o raciocínio que mais se coaduna com a realidade das coisas, aplicado na jurisprudência em geral, tanto no Superior Tribunal de Justiça (REsp 151.150-SC, Rel.Min. José Dantas, j. 7.4.98) como no Supremo Tribunal Federal (HC 74.608-0-SP, Rel.Min Celso de Mello, j.18.2.97; HC 76.381-5-SP, Rel. Min Carlos Velloso, j. 16.6.98; HC87.662-PE, Rel. Min Carlos Britto. J.5.9.06).

Nesse sentido ainda:

“VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS - O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualifica-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, poder dever de ofício, da repressão penal - O depoimento testemunhal do agente policial somente perderá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando demonstrar- tal como ocorre com as demais testemunhas- que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência” (HC 73.518-5 SP, Rel. Min. Celso de Mello, j.26.3.96). O réu não confessou mas trouxe a juízo uma versão completamente inverossímil dos fatos.

Isto porque ele aduziu ter sido forjado pelos policiais embora tenha admitido que estava com uma pochete com entorpecente no seu interior.

Com efeito, Marcel nos contou que na época usava drogas e comprou R\$ 300,00 em entorpecente porque era usuário de drogas e como iria passar o final de semana em uma festa, resolveu comprar quantidade suficiente para todo o período, no caso, cocaína, crack e maconha.

Ocorre que ele não trouxe sequer uma testemunha apta a comprovar que esta festa realmente existiu, o que não seria nada difícil. Vejamos o que ele disse:

Marcel tem 35 anos de idade. Trabalha como porteiro, com registro em carteira. Atualmente está desempregado. Nunca foi processado anteriormente. É divorciado e tem duas filhas. Na época do ocorrido usava drogas. Desconhece a policial que estava no chat. Na data estava indo para uma festa e queria levar uma quantidade de drogas porque a festa era em um sítio. Estava com cerca de 300 reais. Efetuou a compra e comprou 300 reais em droga. Ia passar o final de semana no sítio. Foi surpreendido por um homem e foi levado por uma viela. Ficou apavorado. O outro policial nunca viu. Comprou cocaína crack e maconha. Comprou umas 5 ou 6 peças de crack, 15 pacotes de maconha e 10 tubinhos de cocaína. Na época trabalhava como banhista em um pet shop isso de segunda a sábado. Estava de folga no dia. Esclarece que a data na denuncia constou errado. Os policiais que não foram identificados pediram dinheiro para o acusado para ser liberado. Esclarece que na hora em que foi acuada na viela por outros policiais eles portavam outra pochete. Pelo que viu outros dois indivíduos que eram traficantes estavam presos e acredita que essa pochete onde constava essa quantia de drogas estava nessa outra pochete. É usuário dos três tipos de droga.

Ou seja, além de não comprovar que a tal festa realmente existiu, pela versão do acusado, os policiais o cercaram em uma viela na posse de uma pochete que provavelmente encontraram com os traficantes que já se encontravam presos por eles e estavam em uma viatura. Então pegaram a pochete dos traficantes que já estavam

presos, interior da qual se encontrava a quantidade de drogas apreendida e atribuíram a propriedade da droga ao interrogando porque não conseguiram chegar no traficante. Aduz que o entorpecente que estava em sua pochete foi a quantidade que ele comprou.

Ou seja, sem sentido algum a versão do acusado.

Daí porque, confrontados os elementos de prova, afigura-se de rigor a condenação.

Passo a dosar a pena:

Fixo a pena base no mínimo legal, 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. Isto porque, a meu sentir, não há razões para que a pena base seja aumentada além do mínimo já que os tipos de entorpecente apreendidos em posse dele bem como a quantidade, não desbordam do que ordinariamente já está previsto no tipo penal. Portanto, quanto a este aspecto, discordo da posição trazida pelo Ministério Público.

Em segunda fase, nada a considerar.

Em terceira fase, pesem as ponderações trazidas pelo Ministério Público, entendo que é o caso de aplicação do tráfico privilegiado, ou seja, a causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006. O réu é primário e não possui Maus antecedentes, fls.29/31. Não se pode presumir, de outra banda, que ele se dedicava à atividade criminosa de forma habitual ou, ainda, que integrasse organização criminosa. Só é viável o afastamento da benesse se a condição de reincidente ou portador de Maus antecedentes, bem como de integrante de organização criminosa ou delinquente habitual, restarem devidamente comprovadas. Não basta que tenha sido preso em flagrante por tráfico para se atribuir ao réu a prática de atividades criminosas que impeçam a redução da pena. É necessário que dos autos, ou das circunstâncias da prisão, sobressaiam elementos indicativos de outras atividades ilícitas que não o próprio tráfico em si. E, seguido-se esse entendimento, no caso em apreço, a carga redutora a ser aplicada, considerando-se as circunstâncias do caso concreto, é a máxima, ou seja, 2/3.

Assim sendo, diminuo a pena anteriormente aplicada em 2/3 (dois terços), com o que a reprimenda privativa de liberdade resulta em 01 (ano) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Ausentes outras causas modificadoras da pena, torno definitiva a sanção acima estabelecida. Fixo o regime aberto para início de cumprimento da pena pois entendo ser suficiente a, no caso concreto, coibir a prática delitiva.

Por fim, estabeleço o regime aberto para cumprimento da reprimenda. Isto porque, apesar de o art. 2º, §1º da Lei nº 8.072/90 determinar a fixação de regime inicial fechado para cumprimento do delito de tráfico de entorpecentes, por equipará-lo a hediondo, esta previsão não se aplica ao tráfico privilegiado. Como cediço, em decisão recente, o Supremo Tribunal Federal assentou entendimento no sentido de que o delito de tráfico de drogas, quando há o reconhecimento do privilégio previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, não é equiparado a hediondo, nos termos da Lei nº 8.072/90, conforme se depreende do teor da seguinte ementa:

“HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. APLICAÇÃO DA LEI N. 8.072/90 AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES

PRIVILEGIADO: INVIABILIDADE. HEDIONDEZ NÃO CARACTERIZADA. ORDEM CONCEDIDA. 1. O tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput e § 1º do art. 33 da Lei de Tóxicos. 2. O tratamento penal dirigido ao delito cometido sob o manto do privilégio apresenta contornos mais benignos, menos gravosos, notadamente porque são relevados o envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de Maus antecedentes e a inexistência de vínculo com organização criminosa. 3. Há evidente constrangimento ilegal ao se estipular ao tráfico de entorpecentes privilegiado os rigores da Lei n. 8.072/90. 4. Ordem concedida” (Habeas Corpus nº 118.533/MS - Tribunal Pleno- Rel. Min. Cármen Lúcia - j. 23.06.2016).

No mesmo sentido, os recentes Habeas Corpus nº 136.545, de relatoria do Min. Celso de Mello, j. 07.10.2016; nº 136.762, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, j. 06.10.2016; e Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 937.651, de relatoria

do Min. Roberto Barroso, j. 09.09.2016.

Consequentemente, concedo o apelo em liberdade.

Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação e condeno MARCEL EDUARDO DE OLIVEIRA, RG: 32812169, CPF: 335.732.118-10, nascido em 15/09/1986, natural de São Paulo - SP, filho de Andre Luis Pereira de Oliveira e Filomena da Silva, , qualificado nos autos, como incurso nas sanções do art. 33, "caput" e § 4º da Lei nº 11.343/2006, impondo-lhe a pena de 01 (ano) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, calculados no mínimo legal, e corrigidos desde a data do fato.

Outrossim, não há que se falar em conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos. Ainda que haja entendimento jurisprudencial em sentido contrário e mesmo que nos autos do Habeas Corpus nº 97.256, a expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos" tenha sido incidentalmente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, sendo promulgada a Resolução nº 05/2012 pelo Senado Federal, mantenho meu entendimento no sentido da impossibilidade da referida conversão.

Com efeito, inviável a fixação de penas restritivas aos condenados pelo crime de tráfico de drogas, em qualquer de suas modalidades, havendo ou não aplicação do redutor de pena previsto no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, até porque a conversão das penas privativas de liberdade não é automática, devendo o Magistrado analisar os preceitos estabelecidos do Código Penal.

No presente caso, temos que a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ao réu, que claramente praticava o comércio de drogas é insuficiente para a prevenção e repressão do delito, sendo, portanto, sua concessão, vedada pelo art. 44, inciso III, e 77, II, ambos do Código Penal.

O réu praticou crime gravíssimo, sendo com ele apreendido drogas de alto potencial lesivo, droga esta capaz de atingir a um sem-número de usuários e viciados. Assim, pelas circunstâncias concretas do crime, não há indicação de que tal substituição ou seja suficiente ou recomendável.

Cumram-se as Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo.

Transitada em julgado, determino as providências: 1) Em observância ao item 22, "d", do Capítulo V das Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo, comunique-se o desfecho da ação penal ao serviço distribuidor e ao IIRGD; 2) Lance-se o nome dos condenados no rol dos culpados, fazendo-se as anotações de estilo, nos termos do art. 393, II, do CPP, c.c art. 5º, LVII, da Constituição Federal; 3) Comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, tal qual consta do art. 15, III, da Constituição Federal.

Transitada esta em julgado tornem conclusa para a designação de data para audiência admonitória.

Publicada em audiência.

São Paulo, 12 de setembro de 2022.

Isento de custas.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA